[참 고] 법률행위에 의하지 않은 채권의 이전에 관하여

㉠ 법률의 규정에 의한 채권의 이전에 지명채권양도의 대항요건에 관한 민법규정이 적용되지 않으므로, 채무자로서는 채권의 이전에 관한 통지 등의 유무와 관계없이 「채권자지위를 상실한」 채권양수인의 청구를 거부할 수 있다.[2]

㉡ 양도금지의 특약이 있더라도 전부명령에 따라 채권이 이전될 수 있고, 제449조 제2항은 적용되지 않는다. 즉 집행채권자의 선·악의는 문제되지 않으며, 전부채권자로부터 그 채권을 양수한 이가 악의이거나 중대한 과실이 있었더라도 채무자가 양도금지특약을 근거로 채권양도의 무효를 주장할 수 없다.[3]

㉢ 채권이 양도되고 대항요건을 갖추면 채무이행을 구하는 소에서 양수인만이 정당한 당사자로서 당사자적격을 가지는데,[4] 압류 및 전부명령이 있는 경우에도 지급에 갈음하여 피압류채권이 압류채권자에게 이전되므로(민사집행법 제229조 제3항) 마찬가지이다. 한편 추심명령이 있는 경우에 관하여 종래 대법원은 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 추심명령이 있으면 제3채무자에 대한 이행의 소는 추심채권자만이 제기할 수 있고 채무자는 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 보았는데,[5] 대판(전) 2025.10.23. 2021다252977이 "채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 추심명령이 있더라도 채무자가 제3채무자를 상대로 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보아야 한다"[6]라고 하며 판례를 변경하였다.[7]

제 2 관 채권양도

[3442] Ⅰ. 총 설

1. 의 의

(1) 채권양도란 종래의 채권자(양도인)가 「채권」을 동일성을 유지한 채 이전함을 내용으로 하는, 채권자와 채권자로 될 이(양수인) 사이의 계약을 말하는데, 채권이 동일성을 유지한다는 점에서 경개와 구별된다([3119] 참조).

(2) 현존하는 권리, 즉 채권을 직접 이전시키는 채권양도는 「처분행위」에 해당한다.[1]

(3) 대개 의무부담행위(원인행위)가 채권양도의 원인을 이루고,[2] 많은 경우에 채권양도는 원

1) 전부명령이 확정되면 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때에 피압류채권의 「권면액」만큼 채무자가 채무를 변제한 것으로 보는데(같은 법 제231조), 압류채권자는 독점적인 만족을 얻을 수 있는 반면, 제3채무자의 무자력의 위험을 부담한다.

2) 대판 2003.9.5. 2002다40456. 대판 2007.11.16. 2007다36537도 참조.

3) 대판 2003.12.11. 2001다3771.

4) 소송계속 중 채권이 양도되었다면 양수인의 소송참가 또는 소송인수에 의한 소송승계가 있어야 한다.

5) 대판 2000.4.11. 99다23888 등. 국세징수법에 의한 체납처분으로 채무자의 제3채무자에 대한 채권을 압류하는 경우에도 마찬가지라고 본 대판 2009.11.12. 2009다48879도 참조.

6) 그 이유로, 채무자가 제3채무자를 상대로 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기하는 것은 추심명령에 위반되지 않고, 추심명령이 있다는 이유만으로 채무자가 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 볼 법률적 근거가 없다는 점, 채무자가 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보더라도 추심채권자에게 부당한 결과가 생긴다고 보기 어렵다는 점, 채무자가 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 보더라도 제3채무자에게 불리하지 않고 오히려 응소 부담을 최소화할 수 있다는 점 및 추심명령에 따라 채무자가 당사자적격을 상실한다고 보면 분쟁의 일회적 해결과 소송경제에 반하고 추심채권자의 이익에도 부합하지 않는 결과가 발생할 수 있다는 점을 든다.

7) 소송의 경과는 다음과 같다: 원고는 피고를 상대로 주위적으로 불법행위에 기한 손해배상을 구하고, 예비적으로 부당이득반환을 구하는 소를 제기 → 원심은 추심명령에 따른 일부 당사자적격 상실을 이유로 주위적 청구의 소 중 일부를 각하하고 나머지 주위적 청구는 기각하며, 예비적 청구 중 일부를 인용 → 원심판결 선고 후 원고의 금전채권자가 '원고가 이 사건 소송으로 받을 판결원리금 등 채권'에 관하여 추심명령을 받았고, 성남세무서장이 원고의 부가가치세 등 체납액의 징수를 위하여 동일한 채권을 압류 → 피고는 상고이유로 이 사건 소송물인 채권에 관하여 원심판결 후 새로운 추심명령 등이 있었으므로 원고가 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하였다는 등으로 주장 → 대법원은, 원고가 이 사건 소로써 구하는 채권에 관하여 추심명령과 체납처분에 기한 압류가 있더라도 원고가 그 채권에 관하여 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실한다고 볼 수 없다는 이유로, 피고의 주장을 배척하고 상고를 기각.

1) 물권이 아니라 채권의 이전을 목적으로 한다는 점에서 물권행위와 다르지만 처분행위라는 점에서 물권행위와 같으므로 이를 준물권행위라고 한다.

에 대해서도 효력이 있다(제621조 제2항). 그런데 당사자 사이에 "반대약정이 없으면"[43] 부동산임차인은 임대인에 대하여 그 임대차의 등기절차에 협력할 것을 청구할 수 있다(제621조 제1항). 즉 임차인에게 채권적인 등기청구권이 인정된다(반대: 김형배 Ⅰ, 412면).

② 임차권등기를 마치면, 제3자가 임대인인 소유자로부터 임차부동산을 양수한 경우에, 종래의 임대차는 신 소유자와 임차인 사이에 존속하는 것으로 되어 신 소유자의 인도청구를 거절할 수 있다. 그런데 주택임대차법 제3조의4 및 상가임대차법 제7조와 달리 우선변제권이 인정되지 않지만, 임차보증금이 등기되면(부동산등기법 제74조 제5호) 임차부동산의 양수인에 대하여 임차보증금(특히 그 반환에 관한 동시이행관계)을 주장할 수 있다.

③ 특약이 없는 한 연체차임채권이 당연히 신 소유자에게 이전되지 않는데, 구 소유자와의 사이에 있었던 특약 중 등기사항(부동산등기법 제74조 참조)에 관해서는 그것이 등기되어야 신 소유자에게 대항할 수 있다.

④ 임차권등기를 마친 경우에, 당사자 사이에 다른 약정이 없는 한 임대차 종료 후 임대인의 임차보증금반환의무와 임차인의 임차권등기말소의무는 동시이행관계에 있으므로, 임차인은 임차권등기말소의무를 이행하거나 이행제공을 하여 상대방을 이행지체에 빠뜨려야 비로소 임차보증금에 대한 지연손해금의 지급을 청구할 수 있음은 당연하다.[44]

(3) 한편 건물의 소유를 목적으로 하는 토지임대차(즉 건물대지임대차)를 등기하지 않았더라도, 임차인이 그 지상건물을 등기하면[45] 제3자에 대하여 임대차의 효력이 있다(제622조 제1항).[46] 그러나 대지에 관한 적법한 임차권(적법한 임차권 양도나 전대차를 포함한다)이 없다면, 그 대지상의 건물에 관하여 등기하였더라도 제622조는 적용되지 않는다.[47][48]

한편 건물이 임대차기간의 만료 전에 멸실 또는 후폐(朽廢)한 경우에 토지임대차는 그 효력을 잃는다(같은 조 제2항).

(4) 임차인은 점유보호청구권을 행사하거나 임대인의 물권적 청구권을 대위행사하여 불법점유자를 배제할 수 있다. 나아가 임차권이 대항력을 취득하면, 임차권 자체에 기한 방해배제청구도 가능하다.[49]

---

43) 임대인의 동의를 요하던 의용민법과 다르다.

44) 대판 2024.12.12. 2024다261989.

45) 지상건물에 대한 소유권보존등기에 한한다는 견해로 이은영, 416면.

46) 토지임차인이 건물에 관하여 등기를 하면 그 건물의 부지이용권에 관해서도 공시되므로 토지의 이해관계인에게 불측의 손해를 주지 않는다는 취지에 기한 것이다. 그러나 토지등기부와 건물등기부가 별개로 존재하므로, 토지의 이해관계인은 토지의 현황을 둘러보고 그 지상에 건물이 있으면 건물등기부도 확인해야 하는 불편이 따른다. 관련하여 건물등기의 지번과 토지등기의 지번이 다른 경우에, 그 건물이 등기부상의 건물표시와 사회통념상 동일성이 있고 그것이 임차한 토지 위에 건립되어 있어서 쉽게 경정등기를 할 수 있는 경우라면 경정등기 전이라도 대항력을 갖추었다고 보아야 한다고 한 대판 1986.11.25. 86다카1119도 참조.

47) 대판 1975.7.30. 74다2032는, 제622조 제1항의 취지는, 토지임차인이 임차지상의 건물을 등기함으로써 임대차의 등기가 없더라도 제3자에게 임대차의 효력을 주장할 수 있다는 것이지, 그러한 건물을 취득한 이에게 당연히 임차권이 생긴다는 것은 아니라고 하였다.

48) **[건물대지임대차의 대항력에 관한 재판례]** ㉠ 대판 2003.2.28. 2000다65802 · 65819는, 제622조 제1항은 건물을 소유하는 토지임차인의 보호를 위하여 건물의 등기로써 토지임대차등기에 갈음하는 효력을 부여하는 것일 뿐이므로 임차인이 그 지상 건물을 등기하기 전에 제3자가 그 토지에 관하여 물권 취득의 등기를 한 때에는 임차인이 그 지상건물을 등기하더라도 그 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생기지 않는다고 하였고, 대판 1996.2.27. 95다29345는, 임차인으로부터 건물의 소유권과 함께 건물의 소유를 목적으로 한 토지의 임차권을 취득한 이가 토지의 임대인에 대한 관계에서 임차권의 양도에 관한 그의 동의가 없어도 임차권의 취득을 대항할 수 있다는 것까지 규정한 것은 아니라고 하였다. ㉡ 대판 1994.11.22. 94다5458은, A가 대지와 건물의 소유자였던 B로부터 이를 임차하였는데 그 후 A가 그 건물을 강제경매절차에서 경락받아 대지에 관한 위 임차권은 등기하지 않은 채 건물에 관하여 A 명의의 소유권이전등기를 경료하였다면, A와 B 사이에 체결된 대지에 관한 임대차계약은 건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차계약이 아니므로, 그 대지에 관한 A의 임차권은 제622조에 따른 대항력을 갖추지 못했다고 하였다.

49) 대판 2002.2.26. 99다67079는, 등기된 임차권에 「담보권적 권능」까지 인정하는바, 임대차기간이 종료되면 용익권적 권능은 임차권등기의 말소등기 없이도 곧바로 소멸하나 담보권적 권능은 곧바로 소멸하지 않고, 임차권자는 임대차기간이 종료한 후에도 임차보증

에, 이로써 소멸하였던 대항력이 당초에 소급하여 회복되는 것이 아니라 그 등기가 마쳐진 때부터 그와는 동일성이 없는 새로운 대항력이 발생한다.[101]

(2) 임차권등기의 비용은 임대인이 부담하고(법 제3조의3 제8항),[102] 임차권등기 후의 소액보증인은 법 제8조에 의한 우선변제권을 가지지 못한다(법 제3조의3 제6항).

(3) 임대인의 임대차보증금반환의무는 임차인의 임차권등기말소의무보다 먼저 이행되어야 할 의무이다.[103]

나. 당사자지위의 변동 [4257]

(1) 임대인지위의 승계(承繼)에 관하여 살펴본다.

① 임차주택의 양수인 기타 임대할 권리를 승계한[104] 이가 임대인의 지위를 승계하는 것(법 제3조 제4항)은 ―임대인이 임대권원을 상실함에 따라 임차권이 소멸하는 경우에 임차인을 보호하기 위한― 법률상의 당연승계로, 양수인은 임차권의 부담 있는 소유권을 취득한다.[105] 즉 임대주택이 양도된 경우에, 양수인은 주택의 소유권과 결합하여 임대인의 임대차계약상 권리 · 의무 일체를 그대로 승계하고, 보증금에 관한 권리 · 의무도 당연히 신소유자인 양수인에게 이전된다. 그 결과 양수인이 임대차보증금반환채무를 면책적으로 인수하고, 양도인은 임대차관계에서 탈퇴하여 임차인에 대한 임대차보증금반환채무를 면한다.[106] 이 경우 양도인은 양수인에게 보증금을 이전할 법정채무를 부담한다(담보책임에 관한 제575조 제2항도 참조). 그리고 승계시점 이전의 연체차임이나 손해배상채권은 승계되지 않는데(양창수 · 김형석, 571면),[107] 보증금에서 이를 공제할 수 있음

101) 대판 2025.4.15. 2024다326398. 따라서 '대항요건 구비 → 주택에 근저당권 설정 → 대항요건 상실 후 임차권등기'의 경우에, 경매절차에서 주택을 매수한 이는 ―근저당권이 소멸하면서 임차권도 소멸하므로(소멸주의: [2425] 참조)― 법 제3조의 임차주택 양수인에 해당하지 않는다.

102) 임차인은 민사소송으로 그 비용을 청구하거나, 상계의 자동채권으로 삼는 등의 방법으로 비용상환청구권을 행사할 수 있다(대판 2025.4.24. 2024다221455).

103) 대판 2005.6.9. 2005다4529는, 이미 사실상 이행지체에 빠진 임대인의 임대차보증금의 반환의무와 그에 대응하는 임차인의 권리를 보전하기 위하여 새로이 경료하는 임차권등기에 대한 임차인의 말소의무를 동시이행관계에 있는 것으로 해석할 것은 아니고, 특히 임차권등기는 임차인으로 하여금 기왕의 대항력이나 우선변제권을 유지하도록 해 주는 담보적 기능만을 주목적으로 하는 점 등에 비추어 그러하다는 입장이다.
한편 2023년 개정으로 법 제3조의3 제3항의 준용규정에 민사집행법 제292조 제3항이 추가됨에 따라 임차권등기명령이 송달되기 전에도 임차권등기명령을 집행할 수 있게 되었다.

104) 예: 미등기건물의 사실상 양수인(대판 1987.3.24. 86다카164).

105) **[임대인지위의 승계 여부에 관한 재판례]** ㉠ 법 제3조 제4항을 적용하기 위하여 주택을 임대할 권리나 이를 수반하는 권리를 종국적 · 확정적으로 이전받아야 하는바, 임대차의 목적인 주택을 신탁법에 따라 신탁한 경우의 수탁자도 이에 해당한다(담보목적의 신탁에 관한 대판 2002.4.12. 2000다70460). 임차인이 임차주택의 소유권을 취득한 경우에도 같은 법리가 적용되어 임차인의 보증금반환채권은 혼동으로 인하여 소멸한다(대판 1996.11.22. 96다38216). 반면 후순위저당권의 실행으로 목적부동산이 경락되어 선순위저당권이 함께 소멸한 경우에, 후순위저당권자에게 대항할 수 있는 임차권이라도 소멸된 선순위저당권보다 뒤에 등기되었거나 대항력을 갖춘 임차권은 함께 소멸하므로, 이 경우의 경락인은 임차주택의 양수인 중에 포함되지 않고, 따라서 임차인은 경락인에 대하여 그 임차권의 효력을 주장할 수 없다(대결 1990.1.23. 89다카33043). ㉡ 임대인이 임차주택의 소유권을 담보목적으로 이전하더라도 임대인지위의 승계문제는 발생하지 않지만(대판 1993.11.23. 93다4083. [2532]에서 본 것처럼 담보제공자인 임대인의 점유할 권리가 소멸하지 않기 때문이다), 담보권의 실행에 의하여 양도담보권자가 종국적으로 임차주택의 소유권을 취득하면, 임대인지위의 승계가 일어난다. 그리고 임대인인 명의신탁자가 명의신탁에 의하여 임차주택의 소유권을 명의수탁자에게 이전한 경우에도 임대인지위의 승계문제는 발생하지 않는다고 할 것이다. 다만 대판 1999.4.23. 98다49753은, 주택의 명의신탁자가 임대차계약을 체결한 후 명의수탁자가 명의신탁자로부터 「주택을 임대할 권리」를 포함하여 주택에 대한 처분권한을 「종국적으로 이전받는」 경우에, 임차인이 주택의 인도와 주민등록을 마친 이상 명의수탁자는 법 제3조 제2항에 의하여 임차인과의 관계에서 그 주택의 양수인으로서 임대인의 지위를 승계하였다고 보았다. ㉢ 대판 2021.10.28. 2021다238650: "주택의 공동임차인 중 1인이라도 주택임대차보호법 제3조 제1항에서 정한 대항력요건을 갖추게 되면 그 대항력은 임대차 전체에 미치므로, 임차건물이 양도되는 경우 특별한 사정이 없는 한 공동임차인에 대한 보증금반환채무 전부가 임대인지위를 승계한 양수인에게 이전되고 양도인의 채무는 소멸한다. 이러한 법리는 계약당사자와 사이에 공동임차인의 임대차보증금 지분을 별도로 정한 경우에도 마찬가지이다."

106) 대판 2003.7.25. 2003다2918(다만 주택임차인이 법인인 경우에 주택양수인이 임대인의 지위를 당연히 승계하지는 않는다고 하였다); 대판 2018.12.27. 2016다265689(다만 "임차주택의 양수인에게 대항할 수 있는 임차권자라도 스스로 임대차관계의 승계를 원하지 아니할 때에는 승계되는 임대차관계의 구속을 면할 수 있다고 보아야 하므로, 임대차기간의 만료 전에 임대인과 합의에 의하여 임대차계약을 해지하고 임대인으로부터 임대차보증금을 반환받을 수 있으며, 이러한 경우 임차주택의 양수인은 임대인의 지위를 승계하지 아니한다"); 대판 2022.3.17. 2021다210720.

107) 상가임대차에 관한 대판 2008.10.9. 2008다3022 참조.

고(제1041조. 제1019조 제1항 단서도 참조), 이에 대한 가정법원의 수리심판[63]이 있어야 한다. 포기의 효과를 고려하여 상속인의 진의를 확인하고 상속재산을 둘러싼 법률관계를 명확하게 할 필요 때문에 요식행위로 한 것이다.[64] 상속포기의 신고가 창설적 신고임은 당연하다.

(2) 포기는 상대방 없는 단독행위로서 행위능력을 요하는 외에 ① 포괄적 · 무조건적이어야 하고,[65] ② 특정인을 위한 상대적 포기는 허용되지 않는다.[66]

(3) 포기는 승인의 효력이 발생하기 전에 행해져야 하고,[67] 단순승인이 의제되는 경우에 포기는 부적법하다.[68]

(4) 포기의 철회불가 및 포기의 무효와 취소에 관해서는 [5269] 이하 참조.

[5244] **다. 포기의 효과**

(1) 포기는 「소급효」를 가진다. 즉 상속의 포기는 상속개시된 때에 소급하여 그 효력이 있다(제1042조).[69] 그런데 상속포기의 효력은 피상속인의 사망으로 개시된 상속에만 미치고, 그 후 피상속인을 피대습자로 하여 개시된 대습상속에까지 미치지는 않는다.[70]

(2) 포기자의 상속분의 귀속을 본다.

① 피상속인의 직계비속인 단독상속인 또는 공동상속인 전원이 포기한 경우에 그 직계비속이 (본위)상속인으로 되는데,[71] 그 직계비속도 상속을 포기할 수 있다.[72] 직계비속이 없으면 법정상속순위에 따라 상속인이 결정된다.

② 상속인이 수인인 경우에, 그중 일부가 상속을 포기하면 그 상속분은 상속분의 비율로 나

---

63) 신고자가 상속인인지, 신고자의 진의에 기한 것인지, 숙려기간 내인지 등을 심사하는데(형식적 심사권), 신고의 동기나 이유는 불문한다.

64) 상속개시 전의 포기약정은 그 효력이 없다. 대판 1998.7.24. 98다9021 참조.

65) 조건부 포기나 상속재산 일부의 포기는 허용되지 않는다. 참고로 대판 1995.11.14. 95다27554: "상속의 포기는 상속인이 법원에 대하여 하는 단독의 의사표시로서 포괄적 · 무조건적으로 하여야 하므로, 상속포기는 재산목록을 첨부하거나 특정할 필요가 없다고 할 것이고, 상속포기서에 상속재산의 목록을 첨부했다 하더라도 그 목록에 기재된 부동산 및 누락된 부동산의 수효 등과 제반 사정에 비추어 상속재산을 참고자료로 예시한 것에 불과하다고 보여지는 이상, 포기 당시 첨부된 재산목록에 포함되어 있지 않은 재산의 경우에도 상속포기의 효력은 미친다."

66) 다만 공동상속인 전원이 포기함에 따라 결과적으로 특정상속인에게 상속재산이 집중되는 것은 앞에서 본 바와 같이 허용된다.

67) 대판 1998.7.24. 98다9021.

68) 대판 1983.6.28. 82도2421 참조.

69) 포기의 소급효와 관련하여 채권자취소권의 대상이 아니라고 한 대판 2011.6.9. 2011다29307 및 혼동에 의한 손해배상청구권과 상속포기에 관한 대판 2005.1.14. 2003다38573 · 38580 참조.
참고로 대판 2009.10.15. 2009다49964: "원고가 피고의 사망사실을 모르고 사망자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우에, […] 실질적인 피고는 당사자능력이 없어 소송당사자가 될 수 없는 사망자가 아니라 처음부터 사망자의 상속자이고 다만 그 표시에 잘못이 있는 것에 지나지 않는다고 인정되면 사망자의 상속인으로 피고의 표시를 정정할 수 있다 할 것인바, 상속개시 이후 상속의 포기를 통한 상속채무의 순차적 승계 및 그에 따른 상속채무자 확정의 곤란성 등 상속제도의 특성에 비추어 위의 법리는 채권자가 채무자의 사망 이후 그 1순위상속인의 상속포기사실을 알지 못하고 1순위상속인을 상대로 소를 제기한 경우에도 채권자가 의도한 실질적 피고의 동일성에 관한 위 전제요건이 충족되는 한 마찬가지로 적용이 된다." 상속포기자를 집행채무자로 한 채권압류 및 전부명령의 실체법상의 효력에 관한 대판 2002.11.13. 2002다41602도 참조.

70) 대판 2017.1.12. 2014다39824: "상속포기의 효력은 피상속인의 사망으로 개시된 상속에만 미치고, 그 후 피상속인을 피대습자로 하여 개시된 대습상속에까지 미치지는 않는다. 대습상속은 상속과는 별개의 원인으로 발생하는 것인데다가 대습상속이 개시되기 전에는 이를 포기하는 것이 허용되지 않기 때문이다. 이는 종전에 상속인의 상속포기로 피대습자의 직계존속이 피대습자를 상속한 경우에도 마찬가지이다. 또한 피대습자의 직계존속이 사망할 당시 피대습자로부터 상속받은 재산 외에 적극재산이든 소극재산이든 고유재산을 소유하고 있었는지에 따라 달리 볼 이유도 없다. 따라서 피상속인의 사망 후 상속채무가 상속재산을 초과하여 상속인인 배우자와 자녀들이 상속포기를 하였는데, 그 후 피상속인의 직계존속이 사망하여 민법 제1001조, 제1003조 제2항에 따라 대습상속이 개시된 경우에 대습상속인이 민법이 정한 절차와 방식에 따라 한정승인이나 상속포기를 하지 않으면 단순승인을 한 것으로 간주된다. 위와 같은 경우에 이미 사망한 피상속인의 배우자와 자녀들에게 피상속인의 직계존속의 사망으로 인한 대습상속도 포기하려는 의사가 있다고 볼 수 있지만, 그들이 상속포기의 절차와 방식에 따라 피상속인의 직계존속에 대한 상속포기를 하지 않으면 효력이 생기지 않는다. 이와 달리 피상속인에 대한 상속포기를 이유로 대습상속 포기의 효력까지 인정한다면 상속포기의 의사를 명확히 하고 법률관계를 획일적으로 처리함으로써 법적 안정성을 꾀하고자 하는 상속포기제도가 잠탈될 우려가 있다."

71) 대판 1995.4.7. 94다11835. 예컨대 채무자인 피상속인이 그의 처와 동시에 사망하고 제1순위상속인인 자녀 전원이 상속을 포기한 경우에, 상속을 포기한 이는 상속개시시부터 상속인이 아니었던 것과 같은 지위에 놓이므로 같은 순위의 다른 상속인이 없어 그 다음 근친인 피상속인의 손자녀들이 차순위의 본위상속인으로서 피상속인의 채무를 상속한다.

72) 대판 1995.9.26. 95다27769.

인의 이익을 지키기 위하여 상속채무에 대한 무한책임(상속인의 고유재산을 포함하여)을 「상속재산을 한도로 하는 유한책임」으로 전환하는 제도가 한정승인이다.[1]

(2) 한정승인은 결과적으로 상속채권자의 희생으로 상속인을 보호하지만, 상속채권자는 원래 상속인의 고유재산을 책임재산으로 고려하지 않았다는 점을 고려하면 부당하다고 단정할 수 없다. 오히려 —가산(家産)이라는 관념이 사라진 이상[2]— 상속재산관리인제도를 두어 피상속인의 재산을 청산한 후 남은 적극재산을 상속인에게 귀속시키는 것을 재산상속제도의 원형으로 삼는 입법적 조치를 고려할 필요가 있을 것이다.[3]

[5339] 2. 방식 및 절차

(1) 상속개시 있음을 안 날부터 또는 제1019조 제3항에 의하여 상속채무가 상속재산을 초과하는 사실을 상속인이 중대한 과실 없이 상속개시일부터 3월의 기간 내에 알지 못하고 단순승인한(또는 단순승인으로 의제되는) 경우에는 그 사실을 안 날부터 3월(숙려기간) 내에 상속재산의 목록을 첨부하여 가정법원에 한정승인의 신고를 해야 한다(제1030조 제1항: 「요식행위」).[4] 특별한정승인의 경우에는, 상속재산 중 이미 처분한 재산이 있으면 그 목록과 가액을 함께 제출해야 한다(제2항).

신고를 받은 가정법원은 형식적 요건을 갖추었는지의 심사를 거쳐[5] 이를 수리한다(라類 가사비송사건). 그리고 상속인이 재산목록을 작성하면서 재산 일부를 고의로 기입하지 않은 경우에 한정승인은 효력이 없고 단순승인한 것으로 본다(제1026조 제3호).

(2) 상속인이 수인인 경우에 상속인 각자는 자기의 그 상속분에 응하여 취득할 재산의 한도에서 그 상속분에 응한 피상속인의 채무와 유증을 변제할 것을 조건으로 상속을 승인할 수 있다(제1029조).

(3) 파산자가 파산선고 후에 한 단순승인이나 포기는 파산재단에 대하여 한정승인의 효력을 가질 뿐이다(채무자회생법 제385조, 제386조).

[5340] 3. 효 과

가. 효과 일반

상속에 의하여 피상속인의 「채무」가 상속인에게 당연히 승계되지만, 한정승인을 한 상속인은 그 채무에 대하여 자기가 상속받은 재산의 한도에서만 「책임」을 진다. 즉 한정승인에 따라 상속재산과 상속인의 고유재산이 분리된다. 그에 따라

---

1) 채무초과의 가업을 승계하여 재건하려는 경우 등에서 유용할 수 있는데, 회생절차와 밀접하게 관련된다.

2) 「부모의 채무를 자식이 승계해야 한다」는 관념은 이제 도의적인 차원에서조차 희미해지고 있다.

3) 상속채권자를 위하여 상속재산의 파산제도를 보완하고 한정승인제도를 폐지함이 바람직하다는 견해로 윤진수, 440면.

4) 제3자의 이해관계에 대한 영향을 고려하여 가정법원에의 신고절차를 요구하는데, 복잡한 절차 때문에 이용도가 그다지 높지 않다.

5) 대결 2006.2.13. 2004스74: "가정법원의 한정승인신고 수리의 심판은 일응 한정승인의 요건을 구비한 것으로 인정한다는 것일 뿐 그 효력을 확정하는 것이 아니고 상속의 한정승인의 효력이 있는지 여부의 최종적인 판단은 실체법에 따라 민사소송에서 결정될 문제이므로, 민법 제1019조 제3항에 의한 한정승인신고의 수리 여부를 심판하는 가정법원으로서는 그 신고가 형식적 요건을 구비한 이상 상속채무가 상속재산을 초과하였다거나 상속인이 중대한 과실 없이 이를 알지 못하였다는 등의 실체적 요건에 대하여는 이를 구비하지 아니하였음이 명백한 경우 외에는 이를 문제삼아 한정승인신고를 불수리할 수 없다."
한편 특별한정승인에 관하여 대판 2021.2.25. 2017다289651: "제1019조 제3항이 신설된 후 상속인이 단순승인을 하거나 단순승인한 것으로 간주된 후에 한정승인신고를 하고 가정법원이 특별한정승인의 요건을 갖추었다는 취지에서 수리심판을 하였다면 상속인이 특별한정승인을 한 것으로 보아야 [하므로, …] 민법 제1019조 제3항이 적용되는 사건에서 상속인이 단순승인을 하거나 민법 제1026조 제1호, 제2호에 따라 단순승인한 것으로 간주된 다음 한정승인신고를 하여 이를 수리하는 심판을 받았다면, 상속채권에 관한 청구를 심리하는 법원은 위 한정승인이 민법 제1019조 제3항에서 정한 요건을 갖춘 특별한정승인으로서 유효한지 여부를 심리 · 판단하여야 한다."

(1) 상속인은 「물적 유한책임」([3020] 참조)을 진다.[6] 즉 채무와 책임이 분리되어 상속인은 상속으로 인하여 취득할 재산의 한도에서만 피상속인의 채무와 유증을 변제하면 된다(제1029조).[7] 상속채권자는 상속인의 고유재산에 대하여 강제집행을 할 수 없고, 상속인에게 영구적 항변권이 발생한다.

① "상속으로 인하여 취득할 재산"은 적극재산뿐만 아니라 상속재산으로부터 생긴 과실이나 불법행위에 기한 손해배상청구권 기타 재산적 가치 있는 법적 지위도 포함한다.

② 채무 자체가 감축되는 것은 아니라 책임이 제한될 뿐이므로,[8] 상속인이 고유재산으로 상속재산 이상의 변제를 하여도 그것이 비채변제로 되지 않고, 한정승인 전에 상속채무에 대하여 보증을 한 이는 채무 전액에 대하여 무한책임을 진다([3425] 참조).

③ 피상속인의 채무와 유증을 변제하고 남은 재산이 있는 경우에 그 재산은 한정승인을 한 상속인에게 귀속된다.[9]

(2) 상속인이 한정승인을 한 경우에 피상속인에 대하여 가졌던 상속인의 재산상의 권리 · 의무는 소멸하지 않는다(제1031조).[10] 즉 상속인은 상속재산에 대하여 제3자와 같은 지위에 서고, 그의 피상속인에 대한 채권은 상속채권자, 수유자와 함께 상속재산으로부터 배당변제를 받으며, 피상속인에 대한 채무는 상속재산으로 상속채권자 등의 강제집행에 복종하게 된다.

나. 특수한 쟁점들 [5341]

(1) 한정승인에 따른 채권자들 사이의 우열을 본다.

① 한정승인자로부터 상속재산에 담보권을 설정받은 이가 상속재산에 관하여 상속채권자에 우선한다는 것이 판례의 입장이다.

[참 고] 대판(전) 2010.3.18. 2007다77781의 다수의견: "법원이 한정승인신고를 수리하게 되면 피상속인의 채무에 대한 상속인의 책임은 상속재산으로 한정되고, 그 결과 상속채권자는 특별한 사정이 없는 한 상속인의 고유재산에 대하여 강제집행을 할 수 없다. 그런데 민법은 한정승인을 한 상속인(이하 '한정승인자'라 한다)에 관하여 그가 상속재산을 은닉하거나 부정소비한 경우 단순승인을 한 것으로 간주하는 것(제1026조 제3호) 외에는 상속재산의 처분행위 자체를 직접적으로 제한하는 규정을 두고 있지 않기 때문에, 한정승인으로 발생하는 위와 같은 책임제한효과로 인하여 한정승인자의 상속재산처분행위가 당연히 제한된다고 할 수는 없다. 또한 민법은 한정승인자가 상속재산으로 상속채권자 등에게 변제하는 절차는 규정하고 있으나(제1032조 이하), 한정승인만으로 상속채권자에게 상속재산에 관하여 한정승인자로부터 물권을 취득한 제3자에 대하여 우선적 지위를 부여하는 규정은 두고 있지 않으며, 민법 제1045조 이하의 재산분리제도와 달리 한정승인이 이루어진 상속재산임을 등기하여 제3자에 대항할 수 있게 하는 규정도 마련하고 있지 않다. 따라서 한정승인자로부터

6) 상속재산의 분리(제1045조 이하)에 의해서는 상속재산 또는 상속인의 고유재산으로부터 사실상의 우선변제를 받을 수 있을 뿐이고, 유한책임으로 되지는 않는다.

7) 유사한 내용의 국세기본법 제24조 제1항 및 그 의미에 관한 대판 1991.4.23. 90누7395도 참조.

8) 피상속인의 보증인에 대한 구상채무에 관해서도, 그것이 상속개시 전에 발생하였는지 여부를 묻지 않고, 한정승인을 한 상속인은 물적 유한책임을 진다.

9) 그 밖에 대판 2022.10.27. 2022다254154 · 254161: "상속채권자가 피상속인에 대하여는 채권을 보유하면서 상속인에 대하여는 채무를 부담하는 경우, 상속이 개시되면 위 채권 및 채무가 모두 상속인에게 귀속되어 상계적상이 생기지만, 상속인이 한정승인을 하면 상속이 개시된 때부터 민법 제1031조에 따라 피상속인의 상속재산과 상속인의 고유재산이 분리되는 결과가 발생하므로, 상속채권자의 피상속인에 대한 채권과 상속인에 대한 채무 사이의 상계는 제3자의 상계에 해당하여 허용될 수 없다. 즉, 상속채권자가 상속이 개시된 후 한정승인 이전에 피상속인에 대한 채권을 자동채권으로 하여 상속인에 대한 채무에 대하여 상계하였더라도, 그 이후 상속인이 한정승인을 하는 경우에는 민법 제1031조의 취지에 따라 상계가 소급하여 효력을 상실하고, 상계의 자동채권인 상속채권자의 피상속인에 대한 채권과 수동채권인 상속인에 대한 채무는 모두 부활한다."

10) 단순승인의 경우에는 혼동으로 소멸한다.

상속재산에 관하여 저당권 등의 담보권을 취득한 사람과 상속채권자 사이의 우열관계는 민법상의 일반원칙에 따라야 하고, 상속채권자가 한정승인의 사유만으로 우선적 지위를 주장할 수는 없다. 그리고 이러한 이치는 한정승인자가 그 저당권 등의 피담보채무를 상속개시 전부터 부담하고 있었다고 하여 달리 볼 것이 아니다."[11]

우리 민법상 한정승인제도는 피상속인의 채무를 제한 없이 승계하여 파탄에 빠지는 것을 방지함으로써 상속인을 보호하려는 데 본래의 목적이 있고, 상속채권자의 보호는, 상속인의 처분행위가 상속재산의 부당한 감소로 이어지는 경우에 단순승인 의제의 불이익(제1026조 제3호)을 부여하거나 한정승인자의 부당한 변제절차에 대한 손해배상책임(제1038조)을 인정하는 정도에서 그친다. 이러한 상황에서 상속채권자는 제1045조에 따라 상속재산과 상속인의 고유재산의 분리를 청구하는 방법을 선택함으로써 상속채권의 책임재산인 상속재산을 보전할 수 있다. 그런데 한정승인에 의해서도, 피상속인의 채무는 전부 승계되지만 그에 대하여 상속재산만이 책임을 지고 상속인의 고유재산은 상속채무의 책임재산이 아니다. 따라서 상속재산은 상속채권자의 채권에 대한 책임재산으로서 상속채권자에게 우선적으로 변제되고 그 채권이 청산되어야 한다. 이러한 점에서 담보권자가 우선한다는 이 판결의 태도는 법정책적으로 재고의 여지가 없지 않다. 즉 상속개시 전부터 한정승인자에 대하여 채권을 가지던 이가 피상속인의 사망이라는 우연한 사정을 계기로 상속재산에 관하여 (저당권을 설정받아) 선순위로 되고 그 결과 상속채권자가 불리하게 되는 것은, 한정승인에서 상속재산이 특별재산이라는 취지에 반한다. 요컨대 한정승인이 상속인을 보호하기 위한 제도이지만, 상속채권자와 상속인의 채권자 사이의 이해를 왜곡해서는 안 될 것이다.

② 한편 대판 2016.5.24. 2015다250574는 상속재산에 대한 상속채권자의 우선적 지위를 인정하였다.[12]

③ 앞의 두 판결을 모아 보면, 한정승인이 있은 경우에 상속재산에 관한 우선순위가 「상속재산에 관하여 저당권 등의 담보권을 취득한 이 → 상속채권자 → 상속인(한정승인자)의 일반채권자」의 3단계로 구성되는데, 이러한 순위는 우리 민법상 인정되기 어렵다.[13] 다른 한편 담보권자가 우선한다는 2007다77781 판결의 태도가 법정책적으로 검토를 요한다는 점은 앞서 본 바와 같다.

[5342] (2) 한정승인의 효력이 있는지 여부의 최종적인 판단은 실체법에 따라 민사소송에서 결정될 문제이므로,[14] 한정승인신고가 수리되더라도 이를 다투는 상속채권자 등 이해관계인은 별도의 소송에서 한정승인의 무효를 주장할 수 있다.

---

11) A가 사망하자 상속인 B가 적법하게 한정승인을 하였고, 그 후 B가 상속재산인 부동산(甲)에 관하여 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 경료한 후 D에게 근저당권을 설정하여 주었다. 한편 A에게 금전을 대여하였던 P는 A 사망 후 B를 상대로 대여금청구소송의 제기하여 승소판결을 받아서 상속재산인 甲에 관한 경매를 신청하였는데, 경매절차에서 근저당권자인 D가 상속채권자인 P에 대한 관계에서 우선변제권을 주장할 수 있는지가 문제되었다. 원심이 甲의 매각대금이 상속채권자인 P에게 우선적으로 배당되어야 한다고 한 것을 대법원은 위의 판시와 함께 파기환송하였다.
이 판결에는 "상속채권자가 한정승인자의 고유재산에 대하여 강제집행할 수 없는 것에 대응하여 한정승인자의 고유채권자는 상속채권자에 우선하여 상속재산에 대하여 강제집행할 수 없다는 의미에서, 상속채권자는 상속재산에 대하여 우선적 권리를 가진다"는 반대의견이 있다.

12) "상속인이 […] 한정승인의 신고를 하게 되면 피상속인의 채무에 대한 한정승인자의 책임은 상속재산으로 한정되고, 그 결과 상속채권자는 특별한 사정이 없는 한 상속인의 고유재산에 대하여 강제집행을 할 수 없으며 상속재산으로부터만 채권의 만족을 받을 수 있다. […] 상속채권자가 아닌 한정승인자의 고유채권자가 상속재산에 관하여 저당권 등의 담보권을 취득한 경우, 담보권을 취득한 채권자와 상속채권자 사이의 우열관계는 민법상 일반원칙에 따라야 하고 상속채권자가 우선적 지위를 주장할 수 없다. 그러나 상속재산에 관하여 담보권을 취득하였다는 등 사정이 없는 이상, 한정승인자의 고유채권자는 상속채권자가 상속재산으로부터 채권의 만족을 받지 못한 상태에서 상속재산을 고유채권에 대한 책임재산으로 삼아 이에 대하여 강제집행을 할 수 없다고 보는 것이 형평의 원칙이나 한정승인제도의 취지에 부합하며, 이는 한정승인자의 고유채무가 조세채무인 경우에도 그것이 상속재산 자체에 대하여 부과된 조세나 가산금, 즉 당해세에 관한 것이 아니라면 마찬가지이다."

13) 이러한 지위가 집행절차에서 관철될 수 있는지 검토할 점이 적지 않다. 주해 상속법(1)/이동진, 486면(조세채권을 포함하여 5단계로 구성한다) 참조.

14) 대판 2002.11.8. 2002다21882.

(3) 한정승인과 관련하여 이행판결의 주문표시방법, 한정승인신고를 하고도 소송과정에서 한정승인의 항변을 하지 않은 상속인이 집행절차에서 한정승인을 주장하여 청구이의의 소를 제기할 수 있는지 등 간과해서는 안 되는 절차법적 쟁점들도 적지 않다.[15]

4. 특별한정승인 [5343]

(1) 한정승인에 관한 특례의 인정을 본다.

① 상속인은 상속개시 있음을 안 날부터 3월 내에 한정승인 또는 포기를 할 수 있는데, 이 기간이 지나치게 단기일 뿐만 아니라 판례가 이 기간의 기산점인 "상속개시 있음을 안 날"이 상속개시의 원인되는 사실의 발생을 알고 또한 자기가 상속인이 되었음을 안 날을 의미하고 상속재산 또는 상속채무 있음을 안 날을 의미하는 것은 아니라고 하였다.[16] 나아가 상속인이 피상속인의 재산상태를 쉽게 파악할 수 없는 경우가 적지 않음에도 불구하고 본인의 의사에 기하지 않고 —자기 고유의 채무가 아닌— 상속채무를 부담하는 것은 불합리하다. 그에 따라 상속인의 적극적인 선택 없이 이 기간이 도과한 경우에 단순승인으로 의제하는 제1026조 제2호가 헌법불합치결정을 받았다.[17]

---

15) **[이에 관한 재판례]** ㉠ 대판 2003.11.14. 2003다30968: "상속의 한정승인은 채무의 존재를 한정하는 것이 아니라 단순히 그 책임의 범위를 한정하는 것에 불과하기 때문에, 상속의 한정승인이 인정되는 경우에도 상속채무가 존재하는 것으로 인정되는 이상, 법원으로서는 상속재산이 없거나 그 상속재산이 상속채무의 변제에 부족하다고 하더라도 상속채무 전부에 대한 이행판결을 선고하여야 하고, 다만, 그 채무가 상속인의 고유재산에 대해서는 강제집행을 할 수 없는 성질을 가지고 있으므로, 집행력을 제한하기 위하여 이행판결의 주문에 상속재산의 한도에서만 집행할 수 있다는 취지를 명시하여야 한다." ㉡ 대결 2005.12.19. 2005그128: "상속채무의 이행을 구하는 소송에서 피고의 한정승인항변이 받아들여져서 원고 승소판결인 집행권원 자체에 '상속재산의 범위 내에서만' 금전채무를 이행할 것을 명하는 이른바 유한책임의 취지가 명시되어 있음에도 불구하고, 상속인의 고유재산임이 명백한 임금채권 등에 대하여 위 집행권원에 기한 압류 및 전부명령이 발령되었을 경우에, 상속인인 피고로서는 책임재산이 될 수 없는 재산에 대하여 강제집행이 행하여졌음을 이유로 제3자이의의 소를 제기하거나, 그 채권압류 및 전부명령 자체에 대한 즉시항고를 제기하여 불복하는 것은 별론으로 하고, 청구에 관한 이의의 소에 의하여 불복할 수는 없다고 보아야 하고, 나아가 만약 그 채권압류 및 전부명령이 이미 확정되어 강제집행절차가 종료된 후에는 집행채권자를 상대로 부당이득의 반환을 구하되, 피전부채권 중 실제로 추심한 금전부분에 관하여는 그 상당액을 반환을 구하고, 아직 추심하지 아니한 부분에 관하여는 그 채권 자체의 양도를 구하는 방법에 의할 수밖에 없다." ㉢ 대판 2006.10.13. 2006다23138은 "채권자가 피상속인의 금전채무를 상속한 상속인을 상대로 그 상속채무의 이행을 구하여 제기한 소송에서 채무자가 한정승인사실을 주장하지 않으면 책임의 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 아니하여 주문에서는 물론 이유에서도 판단되지 않으므로 그에 관하여 기판력이 미치지 않는다. 그러므로 채무자가 한정승인을 하고도 채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결시까지 그 사실을 주장하지 아니하여 책임의 범위에 관한 유보가 없는 판결이 선고되어 확정되었다고 하더라도, 채무자는 그 후 위 한정승인사실을 내세워 청구에 관한 이의의 소를 제기할 수 있다"고 하면서, 종래 해석론상 논의되던, 적법하게 한정승인신고를 하고도 소송과정에서 한정승인의 항변을 하지 않았던 상속인이 집행절차에서 비로소 한정승인을 주장하여 청구이의의 소를 제기할 수 있는지에 관하여 긍정설을 취하였다(한정승인이 있었음에도 불구하고 항변을 하지 아니함으로써 책임재산에 관하여 아무런 유보 없이 판결이 선고된 경우에 그 판결의 기판력을 인정할 것인지에 관하여 법원실무제요 민사집행 [Ⅰ], 159-60면 참조). 참고로 상속포기의 경우에는 다르다. 즉 대판 2009.5.28. 2008다79876: "채무자가 한정승인을 하였으나 채권자가 제기한 소송의 사실심 변론종결시까지 이를 주장하지 아니하는 바람에 책임의 범위에 관하여 아무런 유보 없는 판결이 선고·확정된 경우라 하더라도 채무자가 그 후 위 한정승인사실을 내세워 청구에 관한 이의의 소를 제기하는 것이 허용되는 것은, 한정승인에 의한 책임의 제한은 상속채무의 존재 및 범위의 확정과는 관계없이 다만 판결의 집행대상을 상속재산의 한도로 한정함으로써 판결의 집행력을 제한할 뿐으로, 채권자가 피상속인의 금전채무를 상속한 상속인을 상대로 그 상속채무의 이행을 구하여 제기한 소송에서 채무자가 한정승인사실을 주장하지 않으면 책임의 범위는 현실적인 심판대상으로 등장하지 아니하여 주문에서는 물론 이유에서도 판단되지 않는 관계로 그에 관하여는 기판력이 미치지 않기 때문이다. 위와 같은 기판력에 의한 실권효 제한의 법리는 채무의 상속에 따른 책임의 제한 여부만이 문제되는 한정승인과 달리 상속에 의한 채무의 존재 자체가 문제되어 그에 관한 확정판결의 주문에 당연히 기판력이 미치게 되는 상속포기의 경우에는 적용될 수 없다." ㉣ 대판 2012.5.9. 2012다3197: "피상속인에 대한 채권에 관하여 채권자와 상속인 사이의 전소에서 상속인의 한정승인이 인정되어 상속재산의 한도에서 지급을 명하는 판결이 확정된 때에는 그 채권자가 상속인에 대하여 새로운 소에 의해 위 판결의 기초가 된 전소 사실심의 변론종결시 이전에 존재한 법정단순승인 등 한정승인과 양립할 수 없는 사실을 주장하여 위 채권에 대해 책임의 범위에 관한 유보가 없는 판결을 구하는 것은 허용되지 아니한다. 왜냐하면 전소의 소송물은 직접적으로는 채권(상속채무)의 존재 및 그 범위이지만 한정승인의 존재 및 효력도 이에 준하는 것으로서 심리·판단되었을 뿐만 아니라 한정승인이 인정된 때에는 주문에 책임의 범위에 관한 유보가 명시되므로 한정승인의 존재 및 효력에 대한 전소의 판단에 기판력에 준하는 효력이 있다고 해야 하기 때문이다. 그리고 이러한 법리는 채권자의 급부청구에 대하여 상속인으로부터의 한정승인의 주장이 받아들여져 상속재산의 한도 내에서 지급을 명하는 판결이 확정된 경우와 채권자 스스로 위와 같은 판결을 구하여 그에 따라 판결이 확정된 경우 모두에 마찬가지로 적용된다."

16) 대결 1991.6.11. 91스1 참조.

17) <헌재결 1998.8.27. 96헌가22, 97헌가2·3·9, 96헌바81, 98헌바24·25> [1] 상속인이 귀책사유 없이 상속채무가 적극재산을 초과하는 사실을 알지 못하여 상속개시 있음을 안 날로부터 3월 내에 한정승인 또는 포기를 하지 못한 경우에도 단순승인을 한 것으로 보는 민법 제1026조 제2호는 기본권 제한의 입법한계를 일탈한 것으로 재산권을 보장한 헌법 제23조 제1항, 사적자치권을 보장한 헌법 제10조 제1항에 위반된다.

[2] (1) 민법 제1026조 제2호에 대하여 단순위헌결정을 하여 당장 그 효력을 상실시킬 경우에는 상속인이 상속개시 있음을 안 날로부터 3월 내에 한정승인이나 포기를 하지 아니한 때에 상속으로 인한 법률관계를 확정할 수 있는 법률근거가 없어지는 법적 공백

속을 단순승인하였더라도 이와 관계없이 미성년자인 상속인이 성년이 된 후 한정승인을 할 수 있는 특별절차가 마련되었다.[27]

[5345] 5. 상속재산의 관리와 청산

(1) 한정승인에 따라 상속재산은 분별관리의 대상으로 되는데, 한정승인을 한 상속인은 고유재산에 대한 것과 동일한 주의로 상속재산을 관리[28]해야 하고(제1040조 제3항, 제1022조), 그 밖의 사항에 관해서는 수임인과 유사한 지위를 인정할 것이다. 한정승인을 한 상속인이 수인이라면 가정법원은 공동상속인 중에서[29] 재산관리인을 선임할 수 있는데, 법원이 선임한 관리인은 공동상속인을 대표하여 상속재산의 관리와 채무의 변제에 관한 모든 행위를 할 수 있다(제1040조).

[5346] (2) 한정승인에 의한 청산절차에 관하여 본다.

① 한정승인을 한 상속인은 한정승인을 한 날[30]부터 5일 내에 일반상속채권자와 유증받은 이에 대하여 한정승인의 사실과 2월이 넘는 기간을 정하여 그 기간 내에 채권 또는 수증을 신고할 것을 공고해야 한다(제1032조 제1항). 이러한 「제척공고」의 방법과 최고에 대해서는 법인의 청산에 관한 제88조 제2항, 제3항, 제89조가 준용된다(제1032조 제2항).

② 변제의 순서와 방법은 다음과 같다.

ⓐ 한정승인을 한 상속인은 채권신고기간이 만료되기 전에 일반상속채권자와 수유자에 대하여 상속채권의 변제를 거절할 수 있다(제1033조). 이를 어기고 변제를 한 경우에 제1038조에 따른 책임을 진다.

ⓑ 한정승인을 한 상속인은 채권신고기간이 만료된 후 그 기간 내에 신고한 채권자와 신고하지 않았더라도 자기가 알고 있는 채권자에 대하여 각 채권액의 비율에 응하여 상속재산으로 「배당변제」를 해야 하지만, 우선권 있는 채권자의 권리를 해치지 못한다(제1034조 제1항). 그런데 배당변제를 받을 수 있는 "한정승인자가 알고 있는 채권자"에 해당하는지 여부는, 한정승인자가 채권신고의 최고를 하는 시점이 아니라 배당변제를 하는 시점을 기준으로 판단해야 하고, 따라서 한정승인자가 채권신고의 최고를 할 때에는 알지 못했더라도 그 후 실제로 배당변제를 하기 전까지 알게 된 채권자가 있다면 그 채권자는 배당변제를 받을 수 있다.[31] 한편 특별한정승인을 한

---

26) "제1항에도 불구하고 미성년자인 상속인이 상속채무가 상속재산을 초과하는 상속을 성년이 되기 전에 단순승인한 경우에는 성년이 된 후 그 상속의 상속채무초과사실을 안 날부터 3개월 내에 한정승인을 할 수 있다. 미성년자인 상속인이 제3항에 따른 한정승인을 하지 아니하였거나 할 수 없었던 경우에도 또한 같다."

27) 이러한 개정의 계기를 이룬 <대판(전) 2020.11.19. 2019다232918> [1] 민법 제1019조 제1항, 제3항의 각 기간은 상속에 관한 법률관계를 조기에 안정시켜 법적 불안상태를 막기 위한 제척기간인 점, 미성년자를 보호하기 위해 마련된 법정대리인제도와 민법 제1020조의 내용 및 취지 등을 종합하면, 상속인이 미성년인 경우 민법 제1019조 제3항이나 그 소급적용에 관한 민법 부칙(2002.1.14. 개정법률 부칙 중 2005.12.29. 법률 제7765호로 개정된 것, 이하 같다) 제3항, 제4항에서 정한 '상속채무초과사실을 중대한 과실 없이 제1019조 제1항의 기간 내에 알지 못하였는지'와 '상속채무초과사실을 안 날이 언제인지'를 판단할 때에는 법정대리인의 인식을 기준으로 삼아야 한다. 따라서 미성년 상속인의 법정대리인이 1998. 5. 27. 전에 상속개시 있음과 상속채무초과사실을 모두 알았다면, 앞서 본 민법 부칙규정에 따라 그 상속인에게는 민법 제1019조 제3항이 적용되지 않으므로, 이러한 상속인은 특별한정승인을 할 수 없다. 또한 법정대리인이 상속채무초과사실을 안 날이 1998. 5. 27. 이후여서 상속인에게 민법 제1019조 제3항이 적용되더라도, 법정대리인이 위와 같이 상속채무초과사실을 안 날을 기준으로 특별한정승인에 관한 3월의 제척기간이 지나게 되면, 그 상속인에 대해서는 기존의 단순승인의 법률관계가 그대로 확정되는 효과가 발생한다.

[2] [다수의견] 미성년 상속인의 법정대리인이 인식한 바를 기준으로 '상속채무초과사실을 중대한 과실 없이 알지 못하였는지 여부'와 '이를 알게 된 날'을 정한 다음 이를 토대로 살폈을 때 특별한정승인규정이 애당초 적용되지 않거나 특별한정승인의 제척기간이 이미 지난 것으로 판명되면, 단순승인의 법률관계가 그대로 확정된다. 그러므로 이러한 효과가 발생한 이후 상속인이 성년에 이르더라도 상속개시 있음과 상속채무초과사실에 관하여 상속인 본인 스스로의 인식을 기준으로 특별한정승인규정이 적용되고 제척기간이 별도로 기산되어야 함을 내세워 새롭게 특별한정승인을 할 수는 없다고 보아야 한다.

28) 처분은 단순승인의제로 귀결된다.

29) 대판 1979.12.27. 76그2는 공동상속인 아닌 이를 선임하면 위법하다고 했다.

30) 공동상속인 중에서 선임된 관리인이 공고하는 경우에는 관리인이 그 선임을 안 날(제1040조 제3항 단서).

경우에, 그 상속인은 상속재산 중 남아있는 재산과 함께 이미 처분한 재산의 가액을 합하여 배당변제를 해야 하는데, 한정승인을 하기 전에 상속채권자나 수유자에 대하여 변제한 가액은 이미 처분한 재산의 가액에서 제외한다(제1034조 제2항). 변제기 미도래의 채권, 조건부 또는 기한부의 채권과 존속기간이 불확정한 채권도 —법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여— 변제해야 한다(제1035조). 그리고 수유자는 상속채권자에 대한 변제가 완료된 경우에만 변제받을 수 있다(제1036조).[32] 그 밖에 변제를 위하여 상속재산의 전부 또는 일부를 매각할 필요가 있는 경우에는 민사집행법에 의하여 경매해야 한다(제1037조).[33]

요컨대 배당변제는 우선권 있는 상속채권자, 일반상속채권자, 수유자의 순으로 이루어진다.

ⓒ 채권신고기간 내에 신고하지 않은 상속채권자 또는 수유자로서 상속인이 알지 못한 이는 위의 순서와 방법에 의한 변제가 완료되고 상속재산의 잔여가 있는 경우에 한하여 변제받을 수 있다. 이 경우에도 상속재산에 대하여 질권이나 저당권 등의 특별담보권이 있다면, 그 담보가액의 한도에서 우선변제를 받는다(제1039조).

③ 부당변제로 인한 책임을 본다.

ⓐ 한정승인을 한 상속인이 제1032조에 의한 공고나 최고를 게을리하거나 그 기간이 만료되기 전에 또는 우선순위를 위반하여 변제를 함으로써 다른 상속채권자나 수유자에 대하여 변제할 수 없게 된 경우에, 이로 인하여 생긴 손해를 배상해야 한다. 특별한정승인을 한 경우에 그 이전에 상속채무가 상속재산을 초과함을 알지 못한 데 과실이 있는 상속인이 상속채권자나 수유자에게 변제한 때에도 같다(제1038조 제1항). 이 손해배상청구권에 대해서는 제766조가 준용된다(제1038조 제3항).

ⓑ 한정승인을 한 상속인의 부당변제로 인하여 변제를 받지 못한 상속채권자나 수유자는 그 사정을 알고 변제받은 상속채권자 또는 수유자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. 특별한정승인을 한 경우에 상속채무가 상속재산을 초과함을 알고 변제받은 상속채권자나 수유자가 있는 때에도 같다(제1038조 제2항). 이 구상권에도 제766조가 준용된다(제1038조 제3항).

6. [보론] 상속재산의 파산 [5347]

(1) 상속재산으로 상속채권자 및 수유자에 대한 채무를 완제할 수 없는 때에는 법원은 신청에 의하여 결정으로 파산을 선고한다(채무자회생법[34] 제307조). 즉 상속재산이 채무초과인 경우에, 상속인의 고유재산을 상속채권자로부터 지키고 상속재산을 상속인의 채권자로부터 지키기 위하여 채무자회생법은 상속재산 자체에 대하여 파산능력을 인정한다.[35]

---

31) 대판 2018.11.9. 2015다75308.

32) 잔여액이 모든 수유자를 만족시키기에 부족하다면 유증액의 비율에 따라 배당된다.

33) 관련하여 대판 2013.9.12. 2012다33709: "민법 제1037조에 근거하여 민사집행법 제274조에 따라 행하여지는 상속재산에 대한 형식적 경매는 한정승인자가 상속재산을 한도로 상속채권자나 유증받은 자에 대하여 일괄하여 변제하기 위하여 청산을 목적으로 당해 재산을 현금화하는 절차이므로, 제도의 취지와 목적, 관련 민법규정의 내용, 한정승인자와 상속채권자 등 관련자들의 이해관계 등을 고려할 때 일반채권자인 상속채권자로서는 민사집행법이 아닌 민법 제1034조, 제1035조, 제1036조 등의 규정에 따라 변제받아야 한다고 볼 것이고, 따라서 그 경매에서는 일반채권자의 배당요구가 허용되지 아니한다." 한편 대판 2010.6.24. 2010다14599: "상속부동산에 관하여 민사집행법 제274조 제1항에 따른 형식적 경매절차가 진행된 것이 아니라 담보권 실행을 위한 경매절차가 진행된 경우에는 비록 한정승인절차에서 상속채권자로 신고한 자라고 하더라도 집행권원을 얻어 그 경매절차에서 배당요구를 함으로써 일반채권자로서 배당받을 수 있다."

34) 이하 "법"이라고만 한다.

35) 상속재산의 파산에서 파산주체에 관하여 다양한 입장이 있을 수 있지만, 상속재산 자체를 파산주체로 보아야 한다. "상속재산파산절차는 상속재산 자체에 파산능력을 인정하여 채무초과상태의 상속재산을 엄격한 절차에서 공평하게 청산할 수 있도록 하기 위한 절

(2) 상속재산파산의 절차를 본다. ① 상속재산에 대하여 상속채권자, 수유자, 상속인,[36] 상속재산관리인 및 유언집행자는 파산신청을 할 수 있다(법 제299조 제1항. 제2항의 신청의무도 참조).[37] 공동상속에서 상속인 각자가 파산신청을 할 수 있는 반면, 상속인의 채권자는 신청권자에서 제외된다. ② 제1045조에 따라 재산의 분리를 청구할 수 있는 기간에 한하여 상속재산에 대하여 파산신청을 할 수 있다. 이 경우 그 사이에 한정승인 또는 재산분리가 있은 때에는 상속채권자 및 수유자에 대한 변제가 아직 종료하지 아니한 동안에도 파산신청을 할 수 있다(법 제300조).

(3) 상속재산에 대하여 파산선고가 있으면, 상속재산만으로 파산재단이 구성되고, 상속재산과 고유재산 사이의 혼동이 배제된다(법 제389조). 파산재단인 상속재산에 관하여 상속채권자와 수유자만이 파산채권자로 되는데, 상속채권자가 수유자에 우선하고(법 제443조[38]), 상속인의 채권자가 파산채권자로 되지 못함은 당연하다. 부인(否認)에 관하여 법 제400조 이하 참조.

(4) 인접제도와의 관계를 본다. ① 한정승인이나 재산분리에는 상속재산을 총채권자와의 관계에서 공평하게 청산하는 기능이 약한데, 상속재산에 대한 파산선고가 한정승인이나 재산분리에 영향을 미치지 않지만, 파산취소 또는 파산폐지의 결정이 확정되거나 파산종결의 결정이 있을 때까지 그 절차를 중지한다(법 제346조). ② 상속재산에 대하여 파산선고가 있는 때에는 상속인은 한정승인한 것으로 본다. 다만 제1026조 제3호에 의하여 상속인이 단순승인한 것으로 보는 때에는 그러하지 아니하다(법 제389조 제3항).

[5348] Ⅱ. 재산분리

1. 의 의

가. 개 념

(1) 재산의 분리란 상속개시 후에 상속채권자나 수유자 또는 상속인의 채권자의 청구에 기하여 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리하여 상속개시 전의 책임재산상태를 유지한 채 채권관계가 청산될 수 있도록 하는 법원의 처분을 말한다.[39] 「책임재산」으로서 상속재산 또는 피상속인의 고유재산을 믿고 거래한 채권자가 상속으로 인하여 상속재산과 상속인의 고유재산이 혼합됨으로써 받게 될 불이익을 방지함에 그 취지가 있는데, 양 재산이 완전히 별개 · 독립의 것으로 되는 것은 아니고 책임재산에 대한 채권자들의 우열을 정할 뿐이다.

상속인이 포기나 한정승인을 통하여 자기의 이익을 지킬 수 있는 것에 대응하여,[40] 재산분리는 상속채권자 · 수유자 · 상속인의 채권자로 하여금 자신들의 이익을 지킬 수 있도록 하는 제도이지만, 상속재산이 채무초과인 경우에 한정승인과 실질적으로 다르지 않을 뿐만 아니라 상속

차"라는 대판 2024.1.4. 2022다285097 참조.

36) 상속을 승인하기 전이라도.

37) 피상속인에 대하여 파산이 신청되었거나 파산이 선고된 후 피상속인이 사망하여 상속이 개시된 경우에도 상속재산파산으로 이행(移行)한다(법 제308조 참조).

38) 한편 상속인에 대하여 파산선고가 있는 경우에, 법 제444조에 따라 상속인의 고유재산에 관하여 상속인의 채권자가 상속채권자 및 수유자에 우선하는 반면, 상속재산에 관해서는 상속채권자 및 수유자가 상속인의 채권자에 우선한다.

39) 상속재산의 총액이 3,000만 원인 반면 상속인의 고유재산은 5,000만 원의 소극재산뿐인 경우에, 단순승인을 하면 상속인의 재산은 2,000만 원의 소극재산뿐인바, 그로 인하여 상속채권자나 수유자가 불리하게 된다. 이러한 경우에 상속채권자나 수유자는 상속재산으로부터 우선적으로 변제받을 수 있도록 상속재산을 청산하는 제도가 재산분리제도이다. 상속재산이 채무초과인 경우에도 같다.

40) 상속재산이 채무초과인 경우에 포기나 한정승인을 할 것인지 여부는 상속인의 자유에 속한다.